

1500720-53.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Ameaça
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/05/2022
... Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500720-53.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500720-53.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça (Violência Doméstica Contra a Mulher)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ANDRÉ APARECIDO DELLI AGOSTINHO

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dry(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ANDRÉ APARECIDO DELLI AGOSTINHO foi denunciado por incursão no caput do art. 150 c.c. alíneas f e h do inciso II do art. 61, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 11 de abril de 2022, por volta das 10h20min, na rua Francisco da Paz, 303, Vila Dirce, nesta cidade e comarca de Mauá, o acusado entrou e permaneceu, clandestina, astuciosamente e contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, na casa de Maria Marilene Delli Agostinho e Dirceu Natalino Delli Agostinho, ambos com mais de sessenta anos de idade, e em suas dependências.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl. 112) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a vítima foi devidamente inquirida e o réu foi interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos

termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteia a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão, sob regime penitenciário inicial aberto.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Procede a acusação.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 4), boletim de ocorrência (fls. 42-7) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, na fase administrativa o réu declarou que ingressou na residência das vítimas, pois tinha a chave do imóvel (fl. 17). Sob o contraditório, foi devidamente interrogado (mídia digital).

A vítima Maria, em solo policial, informou que (sic) "eu e meu marido estávamos dormindo, e quando acordamos o André estava no quintal de nossa casa; desde que registramos a ocorrência, nós não permitimos mais que ele entrasse em casa, porque temos medo dele, porque ele sempre esta sob efeito de droga e fica violento com a gente; Eu e meu marido, nos trancamos no quarto e chamamos a policia, porque temos muito medo do André, por tudo que ele já nos fez; O André estava hoje sob efeito de droga hoje, assim como sempre está, quando os policiais chegaram em casa, nós apontamos para eles onde o André estava, e eles entraram em casa, com a nossa permissão e viram o André dentro de um quarto, deitado no chão "; Acrescenta que: "nós temos medo do André; nós precisamos que ele, também, faça um tratamento para dependência química, porque do jeito que ele está ele vai acabar fazendo mal , ou para nós ou para alguém na rua" (fl. 08).

A vítima Dirceu, em solo policial, declarou que (sic) "nesta data, ao acordar, depararam-se com o indiciado no interior do imóvel; Que o indiciado encontrava-se sob efeito de drogas, e com comportamento agressivo, e narra que: "nós estávamos dormindo, e quando acordamos vimos ele no quintal de casa; o André estava sob efeito de droga, porque agora ele só vive sob efeito de droga; ele estava agressivo, e por isso eu e minha esposa nos trancamos no quarto, porque temos muito medo dele, por tudo que ele já nos fez, e chamamos a policia; Quando a policia chegou, mostramos para eles onde o André estava, e eles entraram na casa, com a nossa permissão, e viram o André no quarto;" (sic); Indagada sobre como André adentrou no imóvel, responde: "eu não sei, porque quando acordamos já encontramos ele lá; ele não tem a chave de casa, a não ser que ele tenha feito alguma copia, sem nós sabermos; eu tenho 75 anos de idade e minhas esposa 70 anos de idade, temos medo dele, e precisamos muito que ele, também, faça um tratamento para a dependência química, porque senão isto nunca vai acabar; ele tem ficado cada vez mais violento, temos medo do que ele possa fazer com a gente e com alguém na rua" (fl. 09).

Durante a instrução, Dirceu disse que costumeiramente o réu pulava a grade e acessava o imóvel para comer. No dia do ocorrido ele não entrou na residência, mas os ofendeu pela janela. Após esclarecimentos da d. Promotoria de Justiça, confirmou que o réu entrou e permaneceu em um quarto que fica na garagem do seu imóvel. Disse que ele entrou nesse quarto sem o seu consentimento, pediu comida, tanto que lhe entregaram comida por meio de uma janela. Ato contínuo, André desceu para a garagem, contra a sua vontade, e dormiu, quando então acionaram a polícia militar. Questionado pelo d. Defensor, disse que o réu tinha costume de ficar nesse quarto usando drogas, entretanto ele sabia que não o queriam no interior do imóvel (mídia digital).

Sobre a importância da palavra vítima em crimes de violência doméstica, decota-se trecho do voto da lavra do eminente Min. Campos Marques "No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas" (STJ, AgRg no AREsp 213796/DF).

Os policiais militares, na fase antejudiciária, historiaram que, ao atender ocorrência de violação de domicílio no local dos fatos, (sic) 'no piso inferior do imóvel, especificamente em um quarto, com porta, flagraram o indiciado, deitado no chão, aparentando estar "totalmente drogado"' (fls. 05-7).

Assim, diante do depoimento das vítimas, em solo policial e em juízo, devidamente comprovada nos autos a prática do crime de violação de domicílio pelo réu, que ingressou nas dependências da residência de seus pais, contra as suas vontades.

Os diversos registros de ocorrência e pedidos de medida protetiva formulados pelos ofendidos em desfavor de André (fls. 37-47 e 54-5) reforçam ainda mais o fato de não quererem sua presença no imóvel.

Dessa forma, caracterizado o delito, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima no mínimo legal, pelos maus antecedentes (certidão de fl. 55 - proc. 1501396-63.2020), atingindo 01 mês e 05 dias de detenção.

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na sequência, presentes as agravantes da reincidência (certidão fl. 54 - proc. 1500505-14.2021) e das alíneas e (contra ascendente), f (prevalecendo-se das relações domésticas) e h (contra pessoa maior de 60 anos - vítimas com 70 e 75 anos à época dos fatos), todas do inciso II do art. 61 do Código Penal, majoro em 1/3 a reprimenda, totalizando 01 mês e 16 dias de detenção, pena que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, dormindo no interior da residência das vítimas, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decísium sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recruto de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no

caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.).

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravo regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros

elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).

Deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, em atenção ao art. 33 do Código Penal, notadamente pela reincidência, em crimes de violência doméstica, contra as mesmas vítimas, inclusive. Pelas mesmas razões não se aplicam outros benefícios legais, insuficientes para a reprovação da conduta.

POSTO ISSO, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDRÉ APARECIDO DELLI AGOSTINHO, qualificado nos autos, à pena de 01 mês e 16 dias de detenção, sob o regime inicial semiaberto, por incursão no caput do art. 150 c.c. alíneas e, f e h do inciso II do art. 61, ambos do Código Penal.

Denego ao réu o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar. Expeça-se guia provisória com urgência.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA